

任意捜査と強制捜査の区別に関する次の【記述】の①から⑬までの（ ）内には、「任意」又は「強制」のいずれかの語句が入る。②、④、⑦及び⑪の（ ）内に入る語句の組合せとして正しいものは、後記1から6までのうちどれか。

【記述】

刑事訴訟法は、何が強制捜査であるのかについての定義を示していないため、その定義めぐって学説は分かれており、まず、被疑者の逮捕、搜索差押えのような物理的な実力の行使を伴う捜査が(①)捜査の典型であるとされてきたことから、物理的な実力の行使を伴う場合に限るとする説と、それに加えて人に義務を負わせるものも含むとする説とが対立し、後説が従来の通説であった。そして、いかなる場合が人に義務を負わせるものに当たるかの判断基準については、間接強制を伴う場合に限るという考え方と、義務の履行を強制する手段の有無を問わないという考え方に分かれていた。前者の考え方によると、同法第197条第2項の公務所に対する照会は、(②)捜査、同法第226条の第一回公判期日前の証人尋問は、(③)捜査ということになる。ところが、科学技術の発達で犯罪捜査に応用されるようになると、例えば、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行うといった対象者に対する物理的な実力行使や義務付けを伴わない捜査手法が現れてきた。前記各説によると、こうした捜査手法は(④)捜査であることになるが、この結論には大きな疑問がある。また、逆に、例えば、相手方を呼び止めるため、腕に軽く手を掛ける行為のように、物理的な実力が用いられたからといって直ちに(⑤)捜査だとすることが適切か疑わしい場合もある。

その後、物理的な実力によると否とを問わず、個人の権利や法益を侵害するものはすべて(⑥)捜査であるという学説が現れた。この学説によると、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査は、対象者に「みだりに容ぼうを撮影されない自由」が認められるので、(⑦)捜査に該当することになろう。この学説が物理的な実力の行使あるいは人に義務を負わせるという判断基準から脱却しようとした点は正鵠を射ているが、刑事訴訟法の(⑧)捜査に関する要件や手続はかなり厳格であるので、およそ何らかの権利や利益が侵害されればすべて(⑨)捜査であるというのは妥当ではなく、やはり、そのような厳格な要件や手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて(⑩)捜査であると考えるべきであろう。こう考えれば、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査と、住居内の普通では外から見えないような場所にいる人物を高性能の望遠レンズや赤外線フィルムを用いて密かに写真に撮る捜査が、同じ写真撮影でありながら制約される権利や利益の重要性に違いがあるとして、前者を(⑪)捜査、後者を(⑫)捜査とする結論を導くことが可能となり、この結論は常識にも合致する。そして、このように解したとしても、(⑬)捜査は、制約される権利や利益の重要性と当該捜査の必要性・緊急性を比較衡量し、相当と認められる限度でのみ許容されるのであるから、権利や利益の保護に欠けるわけではないのである。

1. ②強制 ④任意 ⑦任意 ⑪任意
2. ②任意 ④任意 ⑦強制 ⑪強制
3. ②強制 ④強制 ⑦任意 ⑪強制
4. ②強制 ④強制 ⑦任意 ⑪任意
5. ②任意 ④任意 ⑦強制 ⑪任意
6. ②任意 ④強制 ⑦強制 ⑪強制

No6

任意捜査と強制捜査の区別

正答率

H20-22

正解

5

96%

() には順に、①＝強制、②＝任意、③＝強制、④＝任意、⑤＝強制、⑥＝強制、⑦＝強制、⑧＝強制、⑨＝強制、⑩＝強制、⑪＝任意、⑫＝強制、⑬＝任意と入り、したがって、正解は肢5となる。

完成全文

刑事訴訟法は、何か強制捜査であるのかについての定義を示していないため、その定義をめぐって学説は分かれており、まず、被疑者の逮捕、搜索差押えのような物理的な実力の行使を伴う捜査が(① 強制)捜査の典型であるとされてきたことから、物理的な実力の行使を伴う場合に限るとする説と、それに加えて人に義務を負わせるものも含むとする説とが対立し、後説が従来の通説であった。そして、いかなる場合が人に義務を負わせるものに当たるかの判断基準については、間接強制を伴う場合に限るという考え方と、義務の履行を強制する手段の有無を問わないという考え方に分かれていた。前者の考え方によると、同法第197条第2項の公務所に対する照会は、(② 任意)捜査、同法第226条の第一回公判期日前の証人尋問は、(③ 強制)捜査ということになる。ところが、科学技術の発達で犯罪捜査に応用されるようになると、例えば、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行うといった対象者に対する物理的な実力行使や義務付けを伴わない捜査手法が現れてきた。前記各説によると、こうした捜査手法は(④ 任意)捜査であることになるが、この結論には大きな疑問がある。また、逆に、例えば、相手方を呼び止めるため、腕に軽く手を掛ける行為のように、物理的な実力が用いられたからといって直ちに(⑤ 強制)捜査だとすることが適切か疑わしい場合もある。

その後、物理的な実力によると否とを問わず、個人の権利や法益を侵害するものはすべて(⑥ 強制)捜査であるという学説が現れた。この学説によると、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査は、対象者に「みだりに容ぼうを撮影されない自由」が認められるので、(⑦ 強制)捜査に該当することになる。この学説が物理的な実力の行使あるいは人に義務を負わせるという判断基準から脱却しようとした点は正鵠を射ているが、刑事訴訟法の(⑧ 強制)捜査に関する要件や手続はかなり厳格であるので、およそ何らかの権利や利益が侵害されればすべて(⑨ 強制)捜査であるというのは妥当ではなく、やはり、そのような厳格な要件や手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて(⑩ 強制)捜査であると考えるべきであろう。こう考えれば、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査と、住居内の普通では外から見えないような場所にいる人物を高性能の望遠レンズや赤外線フィルムを用いて密かに写真に撮る捜査が、同じ写真撮影でありながら制約される権利や利益の重要性に違いがあるとして、前者を(⑪ 任意)捜査、後者を(⑫ 強制)捜査とする結論を導くことが可能となり、この結論は常識にも合致する。そして、このように解したとしても、(⑬ 任意)捜査は、制約される権利や利益の重要性と当該捜査の必要性・緊急性を比較衡量し、相当と認められる限度でのみ許容されるのであるから、権利や利益の保護に欠けるわけではないのである。

①について

①には、被疑者の逮捕、搜索差押えのような物理的な実力の行使を伴う捜査に該当するものが入る。これらの捜査は、従来から強制捜査の典型であるとされてきた。したがって、①には「強制」が入る。

②について

②には、いかなる場合が人に義務を負わせるものにあたるかの判断基準について、間接強制を伴う場合に限るとする考え方に立った場合、197条2項の公務所に対する照会が強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。この点、公務所に対する照会は、履行を強制する方法がないので、任意捜査となる。したがって、②には「任意」が入る。

③について

③には、いかなる場合が人に義務を負わせるものにあたるかの判断基準について、間接強制を伴う場合に限るとする考え方に立った場合、226条の第一回公判期日前の証人尋問が強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。この点、証人は、出頭の義務を負い、正当な理由なく出頭しないと、過料、30万円以下の罰金、1年以下の拘禁刑等の制裁を受け、また勾引されることがある(226条、228条1項、150条、151条、152条)。また、証人は宣誓義務、証言義務も負い、正当な理由なく宣誓又は証言を拒否すると、過料、30万円以下の罰金、1年以下の拘禁刑等の制裁が科されることがある(226条、228条1項、154条、160条、161条)。なお、平成28年改正により、152条の勾引要件が緩和され、「正当な理由がなく、召還に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき」にも勾引が認められることとされた。また、151条(証人不出頭の罪)、161条(宣誓拒絶等の罪)について、法定刑が10万円以下の罰金又は拘留から引き上げられた。よって、第一回公判期日前の証人尋問は間接強制を伴う捜査に該当し、強制捜査にあたる。したがって、③には「強制」が入る。

④について

④には、強制捜査の定義について、物理的な実力の行使を伴う場合に限るとする説又はそれに加えて人に義務を負わせるものも含むとする説に立った場合、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行うといった対象者に対する物理的な実力行使や義務付けを伴わない捜査手法が、強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。当該捜査手法は、物理的な実力行使や義務付けを伴わないものなので、強制捜査にあらず、任意捜査となる。したがって、④には「任意」が入る。

⑤について

本文において「逆に、例えば、相手方を呼び止めるため、腕に軽く手を掛ける行為のように、物理的な実力が用いられたからといって直ちに(⑤)捜査だとなることが適切か疑わしい場合もある。」と述べていることから、⑤には物理的な実力が用いられた場合の素直な帰結が入ることが分かる。したがって、⑤には「強制」が入る。

⑥について

物理的な実力行使を伴わないが、通信の秘密などを侵害する行為をも任意捜査としていることについての批判を受けて「物理的な実力によると否とを問わず、個人の権利や法益を侵害するものはすべて(⑥)捜査であるという学説が現れた。」と述べている。したがって、⑥には「強制」が入る。

⑦について

⑦には、物理的な実力によると否とを問わず、個人の権利や法益を侵害するものはすべて強制捜査であるという学説に立った場合、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査は強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。そして、本間に記述されているとおり、対象者に「みだりに容ぼうを撮影されない自由」が認められると考えると、当該捜査は「みだりに容ぼうを撮影されない自由」を侵害するので、強制捜査といえる。したがって、⑦には「強制」が入る。

⑧⑨⑩について

「刑事訴訟法の（⑧）捜査に関する要件や手続はかなり厳格であるので、およそ何らかの権利や利益が侵害されればすべて（⑨）捜査であるというのは妥当ではなく、やはり、そのような厳格な要件や手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて（⑩）捜査であると考えらるべきであろう。」と述べていることから、⑧、⑨及び⑩にはすべて同じ種類の捜査が入るといえる。そして、⑧には、刑事訴訟法において、捜査に関する要件や手続がかなり厳格である捜査が入る。この点、強制捜査は国民の人権に対する侵害を伴うものなので、法律に特別の定めのある場合でなければ、これを行うことができず（強制処分法定主義、197条1項ただし書）、また原則として令状主義の原則を満たすものでなければならない（憲法33条、35条）。よって、強制処分の方が任意処分よりも要件や手続が厳格である。したがって、⑧には「強制」が入り、⑨及び⑩にも⑧と同様、「強制」が入る。

⑪について

⑪には、厳格な要件や手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて強制捜査であると考えられる見解に立った場合、街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査は強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。この点、街頭等の公の場合にいる場合、その容ぼう等は他人から見られる状況にあることからすれば、承諾なしに写真撮影されないという期待や利益は、厳格な要件及び手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益とはいえない。したがって、⑪には「任意」が入る。

⑫について

⑫には、厳格な要件や手続によって保護する必要があるほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて強制捜査であると考えられる見解に立った場合、住居内の普通では外から見えないような場所にいる人物を高性能の望遠レンズや赤外線フィルムを用いて密かに写真に撮る捜査は強制捜査にあたるか、それとも任意捜査にあたるかについての帰結が入る。この点、住居内の撮影はプライバシーの侵害の程度が高く、重要な権利の侵害といえる。したがって、⑫には「強制」が入る。

⑬について

「そして、このように解したとしても、（⑬）捜査は、制約される権利や利益の重要性と当該捜査の必要性・緊急性を比較衡量し、相当と認められる限度でのみ許容されるのであるから、権利や利益の保護に欠けるわけではないのである。」と述べていることから、⑬には権利や利益の保護に配慮する必要がある捜査の種類が入ることが分かる。そして、⑧のところで先述したとおり、強制捜査は厳格な手続や要件が定められているので、あえて権利や保護に配慮しなければならない捜査は強制捜査ではなく任意捜査であるといえる。したがって、⑬には「任意」が入る。なお、当該判断基準は、任意捜査の限界についての判例（最決昭51.3.16、百選1事件）の基準でもある。